

R.G. RECLAMI n. 11102 /2024 (cui sono stati riuniti i reclami 11102/2024; 11376/24; 11314/24; 11694/24)



Tribunale di Roma

XVI Sezione Civile

Sezione Specializzata Imprese

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott.ssa Cristina Pigozzo | Giudice relatore |
| 3) Dott. Stefano Iannaccone | Giudice |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nei procedimenti di reclamo proposto nella causa n. **11102/2024** avverso
l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure

da

Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,
dall'Avv. MASSAFRA NICOLA e dall'Avv. ADILARDI MARIA
RAFFAELLA (*C.F._1*) VIALE BRUNO BUOZZI 59 00197
ROMA ITALIA;

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con gli avv.ti Aurelio Tricoli (C.F. *C.F._3*) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Fabrizio Ranieri (C.F. *CodiceFiscale_4*), giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel procedimento di primo grado R.G. 34295/23 e qui allegata in copia

Parte_3 , (C.F. *C.F._5*) rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Memoria difensiva di costituzione nel primo grado, dall'Avv.to Francesco Cocola (C.F. *C.F._6*)

Controparte_1 (*C.F._7* , residente in Roma (Rm) Via Colonnello Tommaso Masala 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Azzoni, CF: *C.F._8* e *Parte_4* C.F. *C.F._9* ,

PARTI RECLAMANTI

nei confronti di

Controparte_2 [...] *Controparte_3* con sede in Roma, viale Antonio Ciamarra 270 (c. fisc. *P.IVA_1*), in persona del curatore, avv. *CP_4* rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Pierangeli;

PARTE RECLAMATA

e nei confronti di

Controparte_5 nato a Roma il 24 agosto 1961, c.f. *C.F._10* residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in viale Giulio Cesare, 71 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco, che propone reclamo incidentale;

Parte_5 , nato a Roma il 16.10.1979, (CF *C.F._11*), dom.to in Roma Via Giuffrè e ivi elettivamente domiciliato alla Via Lazio n. 9, presso lo studio del legale, Avv. Francesca Cucchiarelli (CF *C.F._12*),

CP_6 contumace

Il Collegio,

letti gli atti;

sentite le parti;

sciogliendo la riserva assunta all' udienza del 05.06.2024

POSIZIONI DELLE PARTI

Parte_1 , premesso:

- di essere stato consigliere della società Organizzazione_1 con nomina del 23.01.2012 (Parte_2 Presidente e CP_5 di CP_5 Consigliere) fino al 10.01.2014 e poi nel nuovo Cda in data 10.01.2024 sempre in qualità di consigliere (Persona_1 , Presidente; Controparte_5 Consigliere);
- Che in data 31.10.2014 il CdA veniva revocato e sostituito da CP_7 ella persona di Persona_2 , poi sostituito in data 27.01.2015 da Parte_5 e in data 25.05.2015 da CP_6 ;
- Che il consulente del Organizzazione_2 rag. Per_3 poi nominato liquidatore della Org_1 aveva escluso che alla data delle dimissioni dell' Parte_1 la società si trovasse in stato di dissesto, prospettando una liquidazione in bonis;
- Che la società veniva dichiarata fallita nel 2018;

lamentava l'erroneità dell'ordinanza di prime cure che aveva concesso il sequestro conservativo, in parziale accoglimento del ricorso, di tutti i beni costituenti il patrimonio dei Sigg.ri Parte_2 Parte_1 CP_5 CP_5 Parte_3 , Parte_5 , Controparte_1 e CP_6 nonché di tutti i crediti dai medesimi vantati nei confronti dei terzi a qualsivoglia titolo fino alla concorrenza di € 234.147,95, pari al danno commisurato alla differenza fra il passivo accertato e l'attivo realizzato ex art. 2486 ultimo comma c.c..

Quali motivi di doglianza deduceva:

- 1) Assenza di fumus per prescrizione - L'intervenuta prescrizione dell'azione sociale nei confronti dell' Parte_1 in quanto la cessazione della carica era avvenuta in data 31.10.2014; in punto di azione dei creditori, la decorrenza del termine prescrizionale e, quindi, la conoscibilità dello stato di dissesto, doveva retrodatarsi a prima della dichiarazione di fallimento posto che la società Org_1 non

depositava i bilanci dal 2013, che la situazione di dissesto era stata rappresentata nel corso dell'assemblea del 03.04.2015 allorché l'assemblea deliberava di agire contro il Presidente sig.ra *Parte_3* ; che la prospettazione del giudice per la quale doveva applicarsi la prescrizione decennale da reato non poteva valere nei confronti dell' *Parte_1* al quale non erano addebitate né condotte distrattive né condotte di falso in bilancio; peraltro, rimanendo alla data della apertura della procedura concorsuale della *Org_1* il fallimento di detta società era stato dichiarato in data 03.07.2018 e la prescrizione quinquennale era maturata nel giorno del deposito del ricorso per sequestro conservativo; che la deduzione che ad interrompere la prescrizione basterebbe il deposito del ricorso, argomentata ai sensi della Cass. 24891/21, non era conferente in quanto colà si trattava di ricorso ex art. 702 bis cp.c.; il dato testuale chiedeva, invece, la notifica dell'atto con cui si inizia il giudizio e la richiamata pronuncia di legittimità era rimasta isolata;

- 2) Assenza di fumus boni juris per intervenuta rinuncia all'azione ex art. 2933, 2934 e 2476 c.c. nei confronti del Presidente del cda Avv. *Parte_2* deliberata dall'assemblea dei soci in data 10.01.2014 al momento dell'accettazione delle dimissioni dello stesso. L' *Parte_1* chiedeva di beneficiare ai sensi dell'art. 1304 c.c. della rinuncia formulata nei confronti dell'amministratore Avv. *Pt_2*
- 3) Assenza di fumus della futura azione di merito posto che il CdA aveva in data 23.04.2014 e in data 08.06.2014 prospettato ai soci la situazione contabile ed invitato, nell'assemblea del 08.0.2014, a ripristinare l'integrità patrimoniale della società, pena l'accertamento della causa di scioglimento da parte del CdA e la messa in liquidazione; il CdA era stato sostituito da A.U. in data 31.10.2014 prima della scadenza del termine per la ricostituzione del patrimonio sociale; lo stesso consulente del fallimento rag. *Per_3* negava che alla data del 31.10.2014 vi fosse una situazione di insolvenza, rappresentando che vi era un credito di €169.693 nei confronti di *Org_3* e che il dissesto sarebbe stato causato da prelievi oggetto di contestazione, avvenuti nel 2015, cui l' *Parte_1* era estraneo; non era vero che le immobilizzazioni materiali non erano esistenti essendo state detenute da *Org_3* ;
- 4) Assenza del fumus per inesistenza della prova del nesso causale tra le condotte ascritte all' *Parte_1* ed il presunto danno non essendo stata fornita la prova controfattuale che l'eliminazione della condotta inadempiente avrebbe impedito la perdita del capitale sociale, dovendosi dare prova dell'assunzione che siano state intraprese iniziative commerciali al di fuori di una logica conservativa; il criterio dei netti patrimoniali non era applicabile nella fase cautelare;
- 5) Assenza del periculum per assenza di atti dispositivi da parte dell' *Parte_1* a distanza di 5 anni dal Falliment ^{CP-} *Org_1* e di 9 anni dai fatti di causa e

che il periculum in caso di più debitori avvinti da solidarietà debba essere verificato nei confronti di tutti i condebitori in solido;

chiedeva riformare l'ordinanza di accoglimento e rigettare il ricorso ex art. 671 c.p.c.;

Proponeva reclamo anche l'Avv. **Parte_2** il quale, premesso di essere stato Presidente del Cda dal 21.02.2012 al 10.01.2014, contestava:

- Che il giudice dopo avere assegnato termini, aveva sciolto la riserva prima della scadenza del termine (atto depositato dall'avv. il 29.02.2024 ma accettato dalla cancelleria il 04.03.2024; ordinanza emessa il 01.02.24);
- Che il giudice non aveva valutato che la perizia rag. **Per_3** non era firmata né giurata ed era sprovvista di data;
- Che il ruolo dell'avv. **Pt_2** Presidente del Cda, era solo quello di l.r. non avendo alcun potere gestorio, ivi incluso il pagamento dei debiti tributari; che lo stesso non aveva percepito alcun compenso e che il versamento di €10.000 di cui alla delibera del 13.01.2014 era stato disposto a seguito di provvedimento monitorio (D.I. 2042/2015) e PPT (RGE 26701/2015), risultando il **Pt_2** ancora creditore di €25.000 circa;
- Che alcuna condotta penale era ascritta al **Pt_2** sicché non si poteva ritenere l'estensione decennale della prescrizione; invero le distrazioni di cui al verbale di delibera del 03.04.2015 erano state poste in essere successivamente alla cessazione dell'incarico del **Pt_2** il bilancio al 2012 era stato chiuso in positivo e nel corso del 2013 il **Pt_2** non era stato messo a conoscenza di alcun fatto che potesse implicare la perdita della continuità; anche la perizia **Per_3** sosteneva che i flussi di cassa sarebbero stati positivi in assenza dei prelievi di terzi (tra cui non vi sarebbe il **Pt_2** ; che quanto alla asserita distrazione di beni materiali, benché vi fosse un accordo di noleggio di postazioni informatiche in uso agli operatori del Call center con la **Org_4** in previsione di un appalto di servizi, il General Manager del Gruppo, aveva deciso di acquistare 80 postazioni, ribaltando tale operazione da **Controparte_9** a **Controparte_10** [...] titolare del contratto di fornitura dell'attività di contact center con operazione regolare, sicché le asserzioni del Rag. **Per_3** erano puramente presuntive e indimostrate (lo stesso poi era stato liquidato in chirografo per la sua carica di liquidatore benché nominato dal curatore di altra procedura), chiedendo un compenso del tutto in linea con la somma percepita dal **Pt_2**;
- Che, quindi, ogni azione doveva intendersi prescritta stante l'oggettiva percepibilità sin dal 2015 della situazione di insufficienza dell'attivo per notifica di cartelle esattoriali e relazioni Andreoli a **Org_2**

- Che mancava il periculum non essendo sufficiente dedurre l'insufficienza patrimoniale rispetto al danno anche in relazione alla risalenza delle condotte (quasi 10 anni dalla cessazione dalla carica).

Concludeva, chiedendo la revoca dell'ordinanza emessa in data 01.03.2024;

Proponeva reclamo anche *Parte_3* : la stessa premetteva che il *CP_2* le addebitava le seguenti condotte:

- 1) L'indebita prosecuzione dell'attività sociale, nonostante, all'atto della nomina, in sede di discussione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 in ragione di una perdita di esercizio di Euro 92.110,00, il patrimonio netto presentava una consistenza negativa di Euro - 68.946,00;

In relazione a tale condotta il Giudice di prime cure non aveva considerato che i soci erano a conoscenza della situazione critica della società e che il Cda aveva illustrato tale situazione nel verbale assembleare del 23.04.2014, rilevando il PN negativo e la necessità di ricapitalizzazione mediante costituzione di fondo a riserva di almeno €100.000; che in data 20.06.2024, a fronte dell'inerzia dei soci, il CdA aveva dato termine fino al 31.12.2014 per procedere alla ricapitalizzazione, ma che il Cda era stato revocato nell'ottobre 2014. Non aveva, poi, il fallimento allegato quali atti non conservativi fossero stati compiuti ed aveva ommesso di considerare che il PN al 31.12.2014 era positivo per €112.161,00 e che il consulente non aveva sollevato alcun rilievo alle appostazioni;

- 2) Pagamenti in favore della società *CP_11* , in data 5 dicembre 2014 [Euro 150.060,00] e in data 15 gennaio 2015 [Euro 16.673,37] inerenti al "Contratto di Ospitalità" tra la *Org_1* e la *CP_11* concluso il 7 aprile 2014 e avente ad oggetto "l'utilizzo dell'immobile di Via Ostiense 131/L Roma, dotato di postazioni lavorative per attività di call center", contratto che il *CP_2* riteneva mancante di effettiva utilità per la *Org_1* in quanto la società avrebbe già avuto in uso le attrezzature acquistate da *Controparte_9* Invero, il Giudice non aveva considerato che era stato risolto il contratto con *CP_12* e che, quindi, necessitava un'altra sede; inoltre, l'assunto che l'acquisto era inutile stante la presenza dei beni acquistati da *Controparte_13* sarebbe in contrasto con la necessità del consulente di svalutare i beni acquistati in data 01.08.2013 da *Organizzazione_5* in quanto praticamente inesistenti"
- 3) Pagamenti in suo proprio favore, senza alcuna giustificazione per complessivi Euro 39.320,80, e segnatamente: Euro 3.182,40 in data 5 febbraio 2014; Euro 1.591,20 in data 4 giugno 2014; Euro 1.591,20 in data 7 ottobre 2014; Euro 1.591,20 in data 2 dicembre 2014; Euro 3.182,40 in data 5 dicembre 2014; Euro 25.000,00 in data 14 gennaio 2014; Euro 1.591,20 in data 12 febbraio 2015; Euro

1.591,20 in data 17 marzo 2015 [doc. 24 di controparte, movimenti del cc n. 0045021 presso *Organizzazione_6*].

Il giudice non aveva considerato che la somma di €25.000 era stata deliberata in data 14.01.2015 quale Compenso quale Presidente del CdA e che gli altri bonifici di €1591,20 cadauno erano il corrispettivo per contratto di consulenza stipulato in data anteriore all'accettazione della carica (stipulazione del contratto 10.01.2014 – accettazione incarico 23.01.2014).

Quali motivi di impugnazione in diritto rappresentava che il Giudice non aveva considerato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.fall. doveva ritenersi prescritta in quanto la situazione di insolvenza doveva ritenersi conoscibile prima della data della dichiarazione di fallimento già alla data del 10.05.2018 data del deposito del bilancio al 31.12.2017 dal quale emergeva un PPN di - €332.692,00;

Non era, dunque, la data della dichiarazione di *CP_2* del 03.07.2018. Anche così opinando, il deposito del ricorso in data 03.07.2023 non era sufficiente a provocare l'interruzione della prescrizione.

La sentenza della Suprema Corte n. 24891/2021 citata dal giudice - che fa decorrere l'effetto interruttivo dal deposito del ricorso in un caso di procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di revocatoria – è stata smentita dalla successiva ordinanza n. 27944/22 in tema di ricorso monitorio che ha chiarito che l'atto interruttivo della prescrizione ha natura recettizia ed in caso di domanda giudiziale si produce al momento della conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario; il diverso principio per il quale è sufficiente il deposito è stato affermato in tema di revocatoria in quanto essendo azione costitutiva necessaria è lo stesso diritto di agire in revocatoria che si prescrive in 5 anni ed il tempo per la fissazione dell'udienza non può andare a detrimento del ricorrente; invece, nel diritto di credito, il creditore può evitare la prescrizione anche con atto stragiudiziale.

Quanto al documento all. 26, che avrebbe provato la richiesta di restituzione di €61.160,80 alla *Pt_3* per prelievi non giustificati dal 08.01.2015 al 02.04.2015, tale richiesta non configurerebbe una valida interruzione rispetto alla domanda di cui al ricorso (con il quale si addebita la somma di €39.320 per il periodo dal 05.02.2014 al 17.03.2015), posto che sarebbe sovrapponibile solo per l'importo di €3128,40 – bonifici per consulenza.

Inoltre, la prescrizione da reato era priva di sufficiente allegazione sia in diritto in quanto si limitava a richiamare la pluralità di reati di cui all'art. 216 comma I e III l. fall sia art. 217 L. Fall, senza alcuna specifica allegazione del reato richiamato.

In punto di periculum in mora, il *CP_2* aveva solo allegato di avere effettuato verifiche in ordine alla mancanza di beni immobili dei resistenti senza neppure produrre le visure ipocatastali; nel caso specifico, ove nei confronti della

stessa possa considerarsi valida l'interruzione della prescrizione per la sola somma di €3100 vi sarebbe sproporzione rispetto alla misura conservativa, non sussistendo il periculum.

Concludeva, chiedendo, in accoglimento del reclamo, la revoca dell'ordinanza di prime cure.

Proponeva reclamo la signora *Controparte_1* riferendo che alla stessa, estranea alla governance della società fallita, era stata addebitata la compartecipazione alle attività distrattive messe in atto dal *Parte_5* quale, Amministratore Unico.

Invero, alcuni pagamenti effettuati alla *Controparte_14* erano giustificati in quanto corrispettivi di prestazioni per la tenuta della contabilità e redazione buste paga; altri pagamenti – individuati dal consulente in €49.000 in data 19.05.2015; 50.000 in data 19.05.2015, transitati sul conto di *Controparte_1* ; €5446 di fondo cassa in data 01.06.2015, non sono addebitabili alla *CP_1* in quanto effettuati dal convivente *Parte_5* e fatti transitare sul conto della *CP_1* sul quale aveva procura ad operare. La stessa si riservava di depositare le copie delle transazioni effettuate dal *Pt_5* . La stessa aveva, comunque, dedotto l'intervenuta prescrizione.

Concludeva per la revoca dell'ordinanza di prime cure.

Si costituiva nel giudizio di reclamo riunito, *Parte_5* che si associava alle difese del reclamante e chiedeva la revoca del sequestro conservativo evidenziando la situazione di difficoltà economica per il blocco del conto corrente anche in relazione al mantenimento dei figli minori. Riteneva non esservi alcuna prova dell'accordo fraudolento supposto dal *CP_2* tra lo stesso *Pt_5* , la signora *CP_1* ed il padre della stessa *CP_6* :

Si costituiva il signor *Controparte_5* con comparsa del 20.05.24 e reclamo incidentale.

Lo stesso richiamava l'art. 334 c.p.c. e la possibilità di proposizione del reclamo con la comparsa di costituzione in mancanza della notifica del provvedimento cautelare.

Invero, la riforma del 2005 ha disposto che, in caso di riserva di pronuncia, sia onere della cancelleria notificare l'ordinanza e da quel momento decorre il termine per l'impugnazione.

Secondo il costante orientamento della presente sezione, il **reclamo incidentale** tardivo deve considerarsi inammissibile, dacché l'art. 669 terdecies c.p.c. non prende in considerazione l'ipotesi di reclamo incidentale, con la conseguenza che esso **risulta ammissibile solo ove venga proposto dalla parte interessata nel termine ordinario di quindici giorni** dalla pronunzia in udienza ovvero dalla data della comunicazione ovvero ancora dalla data della notificazione di esso, se anteriore. Infatti, la disposizione di carattere eccezionale di cui all'art. 334 c.p.c. non può trovare applicazione analogica nel procedimento del reclamo cautelare atteso che, anche a voler considerare la sua natura impugnatoria, si deve condividere il consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo il quale si tratta di impugnazione diversa da quelle elencate nell'art. 323 c.p.c. che, riguardando le sentenze, sono funzionali all'idoneità al giudicato, funzionalità estranea, invece, al provvedimento cautelare. La disposizione di cui all'art. 334 c.p.c. è espressione di una regola generale del sistema delle impugnazioni che può trovare applicazione anche ai giudizi camerali ma con riguardo all'impugnazione di provvedimenti che, sebbene privi della forma, abbiano comunque carattere decisorio (cfr. Cass. 8654/98 Cass. . 12309/04) e non, quindi, ai provvedimenti cautelari, privi del carattere della decisorietà.

Nel merito, comunque, il **CP_5** ribadisce l'eccezione di prescrizione sostenendo che per stessa ammissione del **CP_2** l'insufficienza del patrimonio sociale si sarebbe già manifestata nel 2015; sostiene comunque la necessità della notifica della domanda giudiziale per l'interruzione della prescrizione; contesta la mancanza di periculum, dimostrata dallo stesso ritardo con il quale è stata chiesta la cautela conservativa rispetto ad un fallimento dichiarato nel 2018. Il **CP_5** ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva non avendo mai accettato la carica di consigliere e comunque, nel merito, manca la deduzione degli eventi pregiudizievoli a fronte dei quali lo stesso sarebbe rimasto inerte.

La deduzione in ordine ai fatti distrattivi quanto all'acquisto di immobilizzazioni materiali sarebbe stata posta sulla base di consulenza di parte che non costituisce prova, fatti di cui il **CP_5** non è mai stato posto a conoscenza non avendo deleghe esecutive; i pagamenti alla **CP_11** erano avvenuti dopo che il CdA era stato revocato; le operazioni distrattive di cui al punto 4.4. sono relative ad attività della **Pt_3** e quelle al punto 4.5 ai signori **CP_1**.

Si costituiva il **CP_2** che chiedeva il rigetto dei reclami: quanto alla prescrizione deduceva che la prosecuzione dell'attività sociale era avvenuta anche tramite la falsificazione delle scritture contabili, con ingenti pagamenti preferenziali e ipotesi distrattive; che comunque bastava il deposito del ricorso per

interrompere la prescrizione; svolgeva poi deduzioni in ordine alle difese delle parti costituite.

OSSERVA

In primo luogo, deve verificarsi l'eccezione di prescrizione.

Il **CP_2** ha proposto istanza di sequestro conservativo prospettando di volere promuovere un'azione di responsabilità nei confronti delle parti convenute: si precisa che si tratta di un prima Cda operativo dal 22.02.2012 al 23.01.24 formato da **Parte_2** Presidente, **Parte_1** e **CP_5** consiglieri; poi subentra altro CdA, a seguito delle dimissioni del **Pt_2** dal 23.01.2014 al 06.02.2015 ove Presidente è **Parte_3** e rimangono consiglieri **Parte_1** e [...] **CP_5** dal 06.02.2015 al 26.02.2015 è **CP_7 Persona_2**, dal 26.02.2015 al 08.06.2015 è **Controparte_15** e dal 08.06.2015 al 09.10.2017 è A.U. **CP_6** [...].

Come è ben noto l'azione sociale rimane sospesa fino alla cessazione della carica e si prescrive in 5 anni; l'azione dei creditori è da ascrivere al novero della responsabilità aquiliana ed il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre dalla conoscibilità dello stato di insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori.

Ai sensi dell'art. 146 L.Fall. il curatore può esercitare entrambe le azioni, rimanendo distinti i presupposti delle due fattispecie.

Dall'esame della documentazione in atti, si rileva che l'azione sociale ex se è prescritta posto che tutti gli amministratori hanno cessato la carica amministrativa oltre 5 anni dalla presentazione del ricorso.

Quanto all'azione di responsabilità a tutela dei creditori, occorre rilevare che l'insufficienza del patrimonio sociale e la conoscibilità della detta situazione deve essere fatta risalire al deposito del bilancio al 31.12.2017, depositato presso la Camera di Commercio in data 10.05.2018. A tale data risultava un patrimonio netto di -332.692.

Non si può dubitare che la funzione del bilancio sia proprio quella di comunicare ai creditori la situazione della società e la sua solvibilità.

La prescrizione decorre, quindi, dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inadatto a soddisfarli. Infatti, che la manifestazione di tale insufficienza coincida con la dichiarazione di fallimento costituisce una presunzione juris tantum, vincibile

dall'amministratore che può provare che l'insufficienza preesisteva ed era conoscibile prima del fallimento.

Pertanto, si deve ritenere che la prescrizione sia maturata per le condotte di mala gestio per le quali non si possano ravvisare reati penali.

Orbene, secondo la curatela vi è stata erosione del capitale sociale già dal 2013 e la governance è rimasta inattiva.

Invero, risulta agli atti che il CdA aveva convocato l'assemblea dei soci e tanto in data 23.04.2014, quanto in data 08.06.2014 aveva prospettato ai soci la situazione contabile come emergente dal progetto di bilancio con patrimonio negativo; aveva invitato, nell'assemblea del 08.06.2014, a ripristinare l'integrità patrimoniale della società, dando termine fino al 31.12.2014 per la ricapitalizzazione, pena l'accertamento della causa di scioglimento. Poi il Cda era stato revocato e sostituito da altro CdA. Vi è, poi, da rilevare che il progetto di bilancio al 31.12.2014 non presenta un patrimonio netto negativo e non è stato predicato di falsità dal consulente del CP_2 che, invece, ritiene che la causa della decozione della società sia da ricondurre ai prelievi ingiustificati del 2015.

Ad ogni buon conto, tale tematica deve ritenersi superata dall'eccepiata prescrizione posto che l'erosione del capitale sociale e l'insufficienza del patrimonio erano, senz'altro, palesi dalla pubblicazione del bilancio al 31.12.2017, avvenuta circa due mesi prima del deposito del ricorso.

Sicché l'azione di responsabilità sociale e dei creditori deve ritenersi prescritta salvo per le (sole) condotte di mala gestio che ridondino in fattispecie penali.

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso (ancorché per difetto di querela), all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, *incidenter tantum*, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cass. III, n.29859/2023; Cass. Civ. sez. III, 25/11/2014, n.24988).

Orbene, la prima condotta denunciata come distrattiva attiene all'acquisto avvenuto in data 01.08.2013 di immobilizzazioni materiali di €121.101 oltre Iva: si trattava di macchine elettroniche d'ufficio per €53.968 e di mobili da ufficio per €63.133,00.

Il consulente del Fallimento rappresenta che l'operazione di cui trattasi viene effettuata subito dopo l'emissione, in data 27 maggio 2013, di una fattura di € 264.325,50 da parte di Controparte_16 (già socio della Org_1 [...] e, nel 2013, della CP_17 a sua volta socio unico della Org_7

[...]

[...] e controllante della **Org_1**) alla **CP_13**. La fattura si riferiva ad una fornitura di “arredo di postazioni call center, fornitura HW e SW servizi di installazione e configurazione SW di base n. 80 postazioni” per € 121.101,00, oltre Iva, e di prestazione “servizi di governance aziendale, riaddebito per utenze telefoniche ed energia elettrica” per € 97.349,93, oltre Iva.

Invero, la difesa di **Pt_2** all’epoca Presidente del Cda, ammette la circostanza che si sia trattato di un acquisto di postazioni personal computers e attrezzature originariamente effettuato da **CP_11** **Controparte_18** - che aveva la liquidità immediata per procedere a tale operazione - poi ribaltato su **CP_3** [...] ed infine vi era stata la cessione, perfettamente regolare tra le due società **Organizzazione_5** e **Org_1** quale titolare del contratto di contact center con **Org_3**.

Il Consulente del Fallimento deduce l’inesistenza di tale acquisto ma dalle evidenze risulta che il materiale sia stato effettivamente depositato presso la [...] **Org_3**. Invero, è stata prodotta missiva dal **CP_2** (in sede di comparsa di costituzione nel reclamo doc. 2) con la quale **Parte_6** in data 15.06.2015 alle richieste dell’A.U. **CP_6** rappresenta che le attrezzature hardware e software “erano state effettivamente consegnate al referente **Org_1** presso la sede **Org_3** di Roma ma che – stante la decisione di **Org_3** di non mettere più a disposizione di **Org_1** gli spazi della sede – poco tempo dopo gli elementi hardware erano stati ritirati dal fornitore e trasferiti in altra sede a noi ignota”. Inoltre, vi è la mail della **Pt_3** che con lettera inviata a mezzo PEC del 20/05/2015 afferma che: “Quanto ai beni che mi richiede, evidentemente i relativi valori si riferiscono a mobili e beni hardware e software del 2010, probabilmente ancora presenti presso il luogo di consegna come da DDT sopra citato, che non ho ritenuto di recuperare dopo la mia nomina essendo di certo a quella data vetusti e quindi da rottamare (in questo modo evitando costi di trasporto e smaltimento)”.

Pertanto, nella delibazione sommaria che connota la presente fase, si osserva che l’operazione di acquisto vi è stata ma vi è stata una responsabilità della governance nella dispersione dei beni, posto che è incontestato che tali beni materiali non siano stati rinvenuti né dal **CP_2** né, prima, dall’A.U. **CP_6** [...] che ne ha chiesto conto alla **Pt_3** e ad **Org_3**.

Ne consegue che al CdA costituito da **Pt_2** **Parte_1** e **CP_5** allo stato, possa essere ascritta la suddetta condotta in quanto gli stessi hanno acquistato i beni e non hanno dato elementi per ritenere che gli stessi non siano responsabili della dispersione dei cespiti. Invero, trattandosi qui di responsabilità sociale da mala gestio e, quindi, di responsabilità contrattuale, incombeva agli stessi l’onere di provare i fatti impeditivi della loro responsabilità, essendo sufficiente la mera allegazione dell’inadempimento da parte del **CP_2**. Né risulta ragionevole la difesa dei consiglieri e dello stesso Presidente di non avere

ruolo esecutivo posto che non è stata dimostrata la sussistenza di deleghe, sicché, anche in ragione degli incarichi dagli stessi ricoperti nelle altre società del gruppo, si deve reputare che gli stessi fossero pienamente e solidalmente responsabili delle scelte gestorie, compresi gli acquisti per importi non irrilevanti ed altrettanto responsabili per la conservazione dei beni sociali.

Il danno deve essere quantificato in €121.101 decorrente al 01.08.2013.

La seconda condotta distrattiva è costituita da due pagamenti effettuati a favore della **CP_11** in ragione di fatture contabilizzate in data 01.12.2014 e 05.12.2014 rispettivamente di €150.060,00 e di €16673,37 in virtù di Contratto di ospitalità sottoscritto tra la stessa **CP_11** e la **Org_1** per la messa a disposizione di un edificio in via Ostiense 131 in Roma dal 07.04.2014 al 31.12.2015), sempre per attività di call center.

La deduzione del **CP_2** in merito alla illiceità della condotta si fonda sulla constatazione che tale pattuizione sarebbe stata “priva di senso” visto che in data 01.08.2013 la **Org_1** aveva acquistato 50 postazioni di cui alla precedente condotta.

Ebbene, si ritiene che tale prospettazione sia inadeguata sotto il profilo probatorio anche nella delibazione sommaria, posto che alcunché viene rappresentato in ordine al personale in essere tale da non potere giustificare la stipulazione del contratto di ospitalità e lo stesso **CP_2** sostiene che le attrezzature acquistate nel 2013 per 50 postazioni non erano più presenti; peraltro, la stessa [...] **Org_3** ha riferito di non avere più dato i propri spazi a disposizione, sicché risulta plausibile che la società abbia dovuto affittare nuovi spazi. La scelta, quindi, pare rientrare nella business judgment rule.

Il fallimento configura anche la bancarotta preferenziale, sull’assunto di un debito erariale di significativo importo, ma invero non prova la formazione cronologica del debito erariale ammesso al passivo, mentre risulta depositata una cartella esattoriale di €63.262 datata 12.01.2015 che non sembra in grado di motivare un addebito per bancarotta preferenziale.

Si deve, quindi, escludere la sussistenza del fumus in relazione a tale condotta.

In merito alle distrazioni imputate alla d.ssa **Pt_3** il Fallimento le contesta distrazioni per l’importo di € 39.320,80 con le seguenti tempistiche: € 3.182,40 in data 5 febbraio 2014; - € 1.591,20 in data 4 giugno 2014; € 1.591,20 in data 7 ottobre 2014; € 1.591,20 in data 2 dicembre 2014; € 3.182,40 in data 5 dicembre 2014; € 25.000,00 in data 14 gennaio 2014; € 1.591,20 in data 12 febbraio 2015; € 1.591,20 in data 17 marzo 2015.

Invero, si deve in primo luogo rilevare che la diffida stragiudiziale notificatale dal **CP_2** riguarda le somme apprese in virtù di un contratto di consulenza

stipulato dalla società con la stessa e altri prelievi non giustificati dal 08.01.2015 al 2.04.2015. Pertanto, per la Pt_3 è stata validamente interrotta la prescrizione in relazione alle condotte colà evidenziate (doc. 5 Reclamo Nuzzo).

Tuttavia, quanto alla somma di €25.000 risulta depositato in atti il verbale dell'assemblea dei soci del 13.01.2014 che delibera di approvare il compenso dell'A.U. per l'anno 2014 nell'importo di €25.000 al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Si deve, quindi, ritenere che stante la non manifesta sproporzione del compenso, la somma risulta giustificata e non può certo assurgere a condotta distrattiva.

Quanto alle ulteriori somme richieste, si tratta di un contratto che la stessa asserisce essere stato stipulato in data anteriore alla sua nomina quale amministratore. Tuttavia, la sua nomina è stata depositata presso la Camera di Commercio in data 23.01.2024 ma le dimissioni del Pt_2 e l'accettazione della sua carica sono anteriori. Posto che trattasi di responsabilità contrattuale la stessa ha mancato di provare il fatto impeditivo e di dimostrare che il contratto che non ha depositato sia stato stipulato da altro amministratore in rappresentanza della società fallita. Risulta, quindi, il fumus del conflitto di interessi e dell'assunzione del fatto nell'alveo della distrazione.

In ultimo, il Fallimento contesta distrazioni di denaro in solido all' CP_7 Pt_5 [...], la moglie/compagna Controparte_1 ed il padre di questa CP_6 [...], futuro A.U. Si tratta di versamenti effettuati per un totale di €144.802,72 a favore di Controparte_19 (per un totale di €6932,6), nonché a favore di conti correnti intestati ad Parte_5, CP_6 e Controparte_1.

Spiccano, in particolare, i bonifici di € 49.000,00 al sig. Parte_5 in data 19 maggio 2015 e di € 50.000,00 alla sig.ra Controparte_1 il 19 maggio 2015.

Merita osservare che in tali date era ancora amministratore Parte_5, subentrando il CP_1 solo in data 08.06.2015.

Come si è visto, Parte_5 si è costituito solo per rappresentare la situazione di difficoltà in cui l'ha posto il sequestro conservativo senza espletare alcuna difesa di merito; la signora CP_1 deduce in modo estremamente generico che la Controparte_19 fornisce prestazioni per la preparazione delle buste paghe senza allegare alcuna documentazione. Quanto ai bonifici eseguiti sui suoi conti, si limita a riferire che il Pt_5 aveva delega ad operare sul suo conto e si riserva di depositare nel prosieguo le movimentazioni bancarie dalle quali si dovrebbe desumere che il suo conto è stato utilizzato solo per transito.

Le posizioni di Controparte_1 e del Pt_5 sono avvinte nella medesima condotta distrattiva posta in essere dal Pt_5 e stante il vincolo familiare risulta,

allo stato dell'approfondimento richiesto e senza alcuna specifica contestazione delle parti (il *Pt_5* è contumace) che il danno possa essere ascrivito anche agli stessi a titolo di concausazione del fatto illecito.

In definitiva, a parziale riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere ritenuto sussistente il presupposto del *fumus boni juris* per l'integrazione delle seguenti condotte distrattive:

- 1) Acquisto beni materiali non rinvenuti: ne rispondono per €121.101 *Parte_2* *Parte_1* *Controparte_5* dall'agosto 2013;
- 2) Prelievi in capo a *Parte_3* per €14.320 (dalla data degli stessi);
- 3) Versamenti a favore di *Parte_5*, *Controparte_1* e *CP_6* per €144.802,72 (dalla data degli stessi).

Verificato il *fumus boni juris*, quanto al **periculum in mora**, si osserva che, a differenza dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nella disciplina del sequestro conservativo il legislatore non richiede la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, ma esclusivamente la concreta possibilità che il patrimonio del debitore risulti inadeguato al soddisfacimento del credito.

Il giudice di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali - quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460, nonché Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081 secondo la quale la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio).

Orbene, la misura cautelare del sequestro conservativo non ha altra funzione che quella di garantire il creditore della permanenza della garanzia patrimoniale, sicché non ha ragion d'essere l'argomento di una disparità di trattamento dei debitori non capienti rispetto a quelli dotati di patrimonio in grado di soddisfare la garanzia del credito.

Rispetto alle allegazioni del **CP_2** di assenza di beni immobiliari che potessero costituire garanzia del credito, le parti resistenti nulla hanno controdedotto, limitandosi a dichiarare che il decorso del tempo aveva da sé evidenziato la carenza del presupposto del periculum. Tale assunto non ha fondamento ove si consideri che nell'ambito temporale garantito dal termine per la prescrizione del proprio diritto di credito, il creditore ha diritto di ottenere tutela se ritiene che la sproporzione del patrimonio dei condebitori rispetto al credito costituisca motivo di pericolo.

Ne consegue che i reclami devono essere accolti per quanto in motivazione con parziale riforma dell'ordinanza impugnata. Il danno viene configurato solo in relazione alle puntuali condotte distrattive ascritte ai diversi componenti della governance societaria come succedutisi.

Spese al merito.

P.Q.M.

Il Collegio, così decidendo sui procedimenti di reclamo,

- 1) Accoglie parzialmente i reclami proposti avverso l'ordinanza di sequestro conservativo depositata in data 01.03.2014 e per l'effetto riforma l'ordinanza impugnata confermando il sequestro conservativo nell'importo di €121.101 a carico solidalmente di **Parte_2**, **Parte_1**, **Controparte_5** nell'importo di €14.320 a carico di **Parte_3** nell'importo di €144.802,72, a carico solidalmente di **Parte_5**, **Controparte_1** e **CP_6**, con interessi legali e rivalutazione dal momento della distrazione.
- 2) Spese al merito

Così deciso nella camera di consiglio dell'11.05.2024.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo